

1500484-50.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, porque ninguém pratica o tráfico da forma como delineada nestes autos se não fosse ligado ao crime organizado, mormente em conhecido ponto de venda de drogas, uma vez que o narcotráfico não admite concorrentes, sendo indicativo claro que ele não praticou o crime ao qual ora condenado de forma esporádica, agindo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500484-50.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500484-50.2022.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adailson Luis de Melo Dias e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. ADAILSON LUÍS DE MELO DIAS qualificado nos autos a fls. 19, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 27 de agosto de 2022, por volta de 0h30min, no cruzamento da Avenida 3 com a Rua 6-B, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria trazido consigo e em depósito, para fins

de tráfico, 56 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 44,69 g, bem como 89 porções de maconha, embaladas individualmente em invólucro plástico, com peso bruto aproximado de 155,31 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por sua vez, ROBERT WILLIAM LOPES ALVES, com qualificação em fls. 43, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 27 de agosto de 2022, por volta de 0h30min, na residência localizada na Avenida 5-B nº 812, nesta cidade e Comarca de Guaíra, guardaria, para fins de tráfico, uma porção de maconha, em forma de tijolo, com peso bruto aproximado de 666,33, bem como uma porção da mesma droga, com peso bruto aproximado de 31,65 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que "policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram um veículo Ford/Focus trafegando pela via, que, repentinamente, alterou sua direção ao perceber a presença da viatura.

Os policiais, então, perseguiram referido veículo e conseguiram pará-lo. Durante a abordagem, os policiais identificaram o condutor do veículo com sendo um motorista do serviço Uber, bem como o denunciado ADAILSON como passageiro. Este, ao descer do veículo, tentou fugir correndo, mas foi perseguido e detido.

Realizada busca pessoa, os policiais apreenderam em poder do denunciado ADAILSON uma sacola plástica contendo 89 porções de maconha e 56 pinos contendo cocaína, além de um telefone celular. Em seguida, o motorista do veículo informou que havia pego o denunciado na residência localizada na Avenida 5-B, nº 812, para onde os policiais se deslocaram.

Chegando no local, os policiais avistaram o denunciado ROBERT WILLIAM de frente ao imóvel, que, ao perceber a aproximação policial, correu para o seu interior.

Rapidamente abordado, os policiais nada apreenderam em poder do denunciado ROBERT WILLIAM. Entretanto, no imóvel, localizaram, sobre um balcão da cozinha, uma porção de maconha fracionada, uma faca, uma balança e uma quantia de R\$ 434,00 em dinheiro trocado. Ainda, enterrado no quintal do imóvel, encontraram um tijolo de maconha. Indagado o denunciado ROBERT WILLIAM pelos policiais, ele afirmou que estava guardando as drogas apreendidas para o denunciado ADAILSON."

A denúncia de fls. 133/136 foi recebida em 31 de agosto de 2022 (fls. 138/139). Os Acusados foram citados a fls. 202 e 204. O Corréu Robert apresentou defesa preliminar a fls. 206/208 e Adailson a fls. 213/216, rejeitadas a fls. 217/218. Durante a instrução foi colhida prova testemunhal e, ao final, os Réus foram interrogados (fls. 275).

Em memoriais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, requerendo a condenação dos Acusados nos termos da denúncia (fls. 273/274).

O Coacusado Adailson, a fls. 276/277, negou a prática do crime, sustentando a improcedência da ação por falta de provas, pleiteando, pois, sua absolvição e, em pedido subsidiário, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Já o Corréu Robert, em fls. 280/289, sustentou a ocorrência de violação de domicílio, que resultaria na nulidade da prova, pugnando, dessa forma, por sua absolvição.

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/08, boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição e apreensão de fls.

15/16, auto de constatação provisória de fls. 57/60, guia de depósito de fls. 162, pelos laudos periciais de fls. 163/164, 165/167, no laudo de constatação definitivo de fls. 270/272, bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria do narcotráfico é certa contra os Réus.

Adailson, nas duas vezes em que foi convidado a prestar depoimento, optou pelo silêncio (cf. fls. 05 e em Juízo).

Robert, que também ficou em silêncio em solo policial, em Juízo negou o teor da denúncia, dizendo ser usuário de maconha e que na data dos fatos estava no interior de sua residência, com sua esposa, quando policiais militares invadiram o local com agressividade, chutando a porta que, inclusive, bateu em sua cunhada, que caiu. Ademais, a maconha ali existente era para seu uso e tinha sido adquirida quando trabalhava em uma fazenda, há cerca de duas semanas.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que os Réus nada tinham a indicar em sua defesa no momento de sua prisão - e Adailson persistiu nisso na fase judicial -, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois ele "assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela" (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

O policial militar Rodrigo declarou que estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo que, ao perceber a viatura, mudou a rota, de forma que optaram por sua abordagem e quando o automóvel estava parando Adailson, que era o passageiro, desceu e tentou correr, sendo perseguido e detido. O motorista do automóvel, que seria Uber, disse, nesse momento, que o passageiro estava "com B0", encontrando com Adailson, em suas vestes, maconha e cocaína. Tendo em vista que o motorista indicou o local onde pegou o passageiro em questão, foram até o local, encontrando Robert na porta que, ao avistar a viatura, se assustou e correu, motivo ao qual perseguiram-no, encontrando em sua casa balança e prato com drogas e, no quintal, maconha enterrada, instante em que ele disse que guardava o entorpecente para Adailson, onde preparavam a droga, ao passo que este nada falou. Por fim, não aparentavam ter feito uso de drogas e no interior da casa havia uma mulher. Em linhas gerais, esse foi o teor do depoimento do policial Alan, que ainda declarou que ambos os Réus eram conhecidos pelo tráfico.

Da análise dos depoimentos inviável se acolher a pretensão trazida pelos Acusados, desprovida de qualquer prova, ficando isolada.

Nesse ponto, não é de se supor que tivessem os policiais invadido a residência de Robert, como por ele declarado, não teria este feito prova, uma vez que é inquestionável que havia ao menos uma mulher na casa - que, segundo o Corréu, teria até mesmo sofrido lesões quando arrombada a porta - ônus que lhe competia, com base no artigo 156 do CPP.

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar exclusivamente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo porque não podem ser descartados, notadamente porque sequer contraditados.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, "Com

relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que ocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

A alegação de invasão do domicílio de Robert deve ser refutada, considerando que o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 10.343/06 é classificado como permanente, de modo que a consumação se arrasta no tempo e permite a prisão em flagrante a qualquer momento. Sendo assim, não era necessária autorização judicial para ingressar na residência em que se encontrava o Acusado, agindo os agentes policiais dentro da exceção à regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, insculpida no artigo 5º, inciso XI, da CF/88: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" (destaquei).

Ao contrário do que sustenta a douta Defesa, não se constata a existência de irregularidade na atuação dos policiais porque havia justa causa, tendo se baseado os agentes públicos no fato de que o Réu, na porta de sua casa, ao avistar a viatura se assustou e entrou correndo para o interior do imóvel, motivo mais do que justificado para afastar a alegação de ilegalidade da prisão, uma vez que os militares foram ao local depois de apreensão de considerável quantidade de entorpecente com o Corréu Adailson, recebendo a informação de que o ilícito foi obtido naquela moradia. Nesse sentido: "inadmissível acenar com 'violação de domicílio', revestida de licitude a conduta dos policiais até porque se cuidava, no caso, de crime permanente, e diante do teor do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, nem era preciso que estivessem eles munidos de mandado judicial de busca, como já se decidiu nesta Corte de Justiça em casos assemelhados (Apel. nº 0000462-78.2014.8.26.0579, rel. Luis Soares de Mello, j. em 27.9.2016; Apel. nº 0001645-68.2014.8.26.0067, rel. Amaro Thomé, j. em 24.11.2016; Apel. nº 0001998-97.2014.8.26.0491, rel. Min. Edison Brandão, j. em 1.11.2016; Apel. nº 0000674-87.2007.8.26.0145, rel. Sérgio Ribas, j. em 31.3.2011). Reiterada aliás essa orientação (HC nº 352.811/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 28.6.2016), inclusive na c. Suprema Corte (RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 5.11.2015)" (TJSP, HC 0023205-68.2017.8.26.0000, 4ª C.D.Crim., Relª Desª Ivana David, j. 31.10.2017).

De igual forma: "recentemente, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616, o C. Supremo Tribunal Federal aprovou a tese, em repercussão geral, segundo a qual a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas posteriormente que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Entendeu-se que, segundo o artigo 33 da Lei de Drogas, configura-se delito permanente guardar entorpecentes ou mantê-los em depósito e o artigo 303 do Código de Processo Penal considera como situação de flagrância aquele que estiver cometendo crime permanente" (TJSP, Revisão Criminal 0008744-28.2016.8.26.0000, 5º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 14.09.2017).

De fato, o procedimento adotado pelos policiais, conforme acima mencionado, está de acordo com o entendimento firmado pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 603.616, representativo da controvérsia: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

Sobre o tema: "a ideia de abuso de autoridade em decorrência da invasão de domicílio, sem ordem judicial, na forma como sugerido pela combativa Defesa, não impede o prosseguimento da ação penal. A conduta imputada ao réu (guardar entorpecente) é crime de natureza permanente, cujo momento consumativo se protraí no tempo, autorizando a qualquer momento a ação policial. Não por outro motivo, recentíssima decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu como legítima a busca e apreensão sem mandado judicial em crime permanente (HC 127457). O relator do caso, ministro Dias Toffoli, lembrou em seu voto que diversos precedentes da Corte apontam no sentido de ser dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias. Nesse caso, não se pode falar em ilicitude das provas obtidas. Isso porque, no caso de crime permanente, explicou o ministro Celso de Mello ao acompanhar o relator, o momento consumativo do delito está sempre em execução. (<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293229> acesso em 11.06.2015).

Por ora, os elementos indiciários contidos no caderno policial sugerem que os milicianos agiram no estrito cumprimento do dever legal, posto que fundadas razões, em torno da possível prática delitiva, inclusive de ordem objetiva, justificaram o ingresso no imóvel apontado na denúncia, como forma de combate à criminalidade que ocorria.

Daí que, na forma como já advertido pela Suprema Corte, 'do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida. (...) Por estar a certeza fora do alcance, a legislação costuma exigir modelos probatórios bem mais modestos para medidas de investigação. Para busca e apreensão, por exemplo, o Código de Processo Penal exige apenas fundadas razões' (STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 05.11.2015)" (STJ, HC 435465, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.02.2018).

A considerável quantidade de cocaína e maconha apreendida com cada um dos Réus, bem como a forma como estava sendo acondicionada, o local da abordagem, o fato de ambos os Acusados serem conhecidos dos meios policiais pela traficância, a tentativa de fuga de Adailson e a faca e balança de precisão localizadas em poder de Robert, ambas com resquícios de entorpecente (cf. fls. 15/16, 163/164 e 165/167), o fato de não estarem sob efeito de entorpecente, indicam a existência do tráfico de drogas. Tais condutas apontam que iriam utilizar o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Por estes fundamentos, seria inviável a desclassificação para o artigo 28, caput, da Lei de Drogas, inclusive porque o simples fato do consumo de narcótico - sequer comprovado - não exclui a possibilidade da traficância, sendo, no mais, condutas que comumente caminham juntas.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Diante deste quadro fático-probatório, urge destacar que os Réus praticaram o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Inexistem, pois, causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos agentes ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo à dosimetria da pena dos Acusados.

Corréu ADAILSON: O Acusado ostenta maus antecedentes, consistente em condenações criminais sem efeitos para reincidência (fls. 64, autos nº 0000452-74.2014.8.26.0210 e fls. 66, processo nº 0000840-30.2014.8.26.0257) e que podem ser utilizadas sem risco de incorrer em bis in idem com a reincidência porque são processos diversos daquele que será abaixo mencionado, mas que demonstram personalidade voltada para a prática da traficância e exigem resposta estatal mais vigorosa. Não bastasse, também é o caso de majorar sua pena-base, considerando a grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, para os padrões desta cidade, abundância esta que evidencia o claro indicativo de que o comércio clandestino seria abastecido por razoável período e adverte que o Réu possuía posição de destaque na traficância, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, com o que promovo o aumento da pena-base em $\frac{1}{2}$ (metade) e a fixo inicialmente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase aumento sua pena em $\frac{1}{3}$ (um terço) em razão da reincidência em crime de roubo (cf. fls. 63, autos nº 0001694-97.2016.8.26.0210), atingindo o patamar de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ele conhecido pela traficância e por se encontrado, juntamente com seu comparsa, com considerável quantidade de entorpecente, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, porque ninguém pratica o tráfico da forma como delineada nestes autos se não fosse ligado ao crime organizado, mormente em conhecido ponto de venda de drogas, uma vez que o narcotráfico não admite concorrentes, sendo indicativo claro que ele não praticou o crime ao qual ora condenado de forma esporádica, agindo de maneira repentina e incontrolável, mas em um verdadeiro meio de trabalho ilícito.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução ($\frac{1}{6}$ a $\frac{2}{3}$) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, com a devida vênua do duto representante ministerial e da insigne advogada de Defesa, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade

do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido

pelo traficante (ainda que seja um “pequeno” traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabilizam a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada que é ao crime delito hediondo no caso concreto, tendo em vista a grande quantidade e diversidade de entorpecente apreendida, dando conta de que o Acusado não pratica esporadicamente o crime, o que foi fielmente retratado no depoimento dos policiais. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: “Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012).

E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita” (TJSP, Ap. 0005407-

56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Corréu ROBERT: O Acusado não possui antecedentes que pudessem ser reconhecidos nesta fase, para não se incorrer em bis in idem com a reincidência, que se falará abaixo. Contudo, nesta primeira fase, urge se destacar que com o Corréu foi apreendida quantidade de droga ainda maior do que aquela encontrada com o primeiro Acusado, de forma que em respeito à individualização da pena, ponderando, ainda, pela diversidade de entorpecentes apreendido para os padrões desta cidade, abundância esta que evidencia o claro indicativo de que o comércio clandestino seria abastecido por razoável período e adverte que o Réu possuía posição de destaque na traficância, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, com o que promovo o aumento da pena-base em $\frac{1}{2}$ (metade) e a fixo inicialmente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase aumento sua pena em $\frac{1}{3}$ (um terço) em razão da reincidência específica (cf. fls. 76, autos nº 1501267-21.2019.8.26.0210), atingindo o patamar de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

Sendo portador de maus antecedentes e reincidente específico, o Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Dessa maneira, torno aquela pena definitiva, ante a inexistência de demais causas legais modificadoras, sendo que o regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, por expressa disposição do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou a substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme acima fundamentado.

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que os Acusados foram condenados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com os Réus foram apreendidos bens e ainda localizada quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento (cf. fls. 162), evidenciando-se serem vinculadas ao tráfico de drogas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, além de objetos e petrechos utilizados para o tráfico de drogas, decreto a perda dos bens e valores apreendidos, que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência:

- a) CONDENO o Corréu ADAILSON LUÍS DE MELO DIAS, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, ao valor unitário de $\frac{1}{30}$ (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do evento delituoso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado e vedadas a conversão em pena restritiva de direitos ou concessão de sursis; e
- b) CONDENO o Corréu ROBERT WILLIAM LOPES ALVES, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, ao valor unitário de $\frac{1}{30}$ (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do evento delituoso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado e vedadas a conversão em pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

No mais, decreto a perda dos bens e dinheiro apreendidos, em favor da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, os Réus, descontentes com a decisão, deverão aguardar o julgamento do recurso presos, motivo por que mantenho suas prisões cautelares, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que está evidenciado que em liberdade atentaram contra a ordem pública, podendo voltar à prática deste pernicioso crime, nada justificando que presos em flagrantes e condenados pela prática de crime hediondo fossem postos em liberdade para que aguardassem assim o julgamento de seu recurso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos Réus no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como se encaminhe os bens e numerários apreendidos em benefício da União.

São devidas custas na forma da lei, delas ficando isentos os Réus por serem beneficiários da Justiça Gratuita, pedidos de fls. 213/216 e 280 que ora defiro uma vez presentes os requisitos legais.

P.R.I.C.

Guaíra, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA